

RAAD VAN STATE, AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK.

A R R E S T

**nr. 180.177 van 28 februari 2008
in de zaak A. 126.544/XII-3650.**

In zake : de NV MEWAF INTERNATIONAL,
die woonplaats kiest bij
advocaat D. Van Heuven,
kantoor houdende te Kortrijk,
President Kennedypark 8b

tegen :

de NATIONALE MAATSCHAPPIJ DER BELGISCHE
SPOORWEGEN (NMBS),
die woonplaats kiest bij
advocaten D. D'Hooghe, F. Vandendriessche en L. Schellekens,
kantoor houdende te 1000 Brussel,
Loksumstraat 25.

DE RAAD VAN STATE, XIIe K A M E R,

Gezien het verzoekschrift dat de NV Mewaf International op
9 september 2002 heeft ingediend om de nietigverklaring te vorderen van :

- “1. Besluit van de NMBS s.d. houdende de gunning van een
overheidsopdracht met bestek nr 77/112/002 betreffende de aankoop van
kantoormeubilair houdende toewijzing van :
 - lot 1 aan de firma TDS Acior voor een jaarlijks bedrag van
€ 753 693,50
 - lot 2 aan de firma TDS Acior voor een jaarlijks bedrag van
€ 272 504,50
 - lot 3 aan de firma Buro Modern voor een jaarlijks bedrag van
€ 54 952,82
 - lot 4 aan de firma TDS Acior voor een jaarlijks bedrag van
€ 817 874,50
2. De beslissing van zelfde datum om genoemde loten niet aan verzoekster
te gunnen.
3. De beslissing s.d. houdende heroverweging van besluit voor wat betreft
lot 3 waarbij dit lot, na terugtrekking van de firma Buro Modern,
eveneens wordt toegewezen aan de firma TDS Acior.
4. De beslissing van zelfde datum waarbij lot 3 niet wordt toegewezen aan
verzoekster”.

Gezien de memories van antwoord en van wederantwoord;

Gezien het verslag opgesteld door eerste auditeur J. Stevens;

Gelet op de beschikking van 7 november 2005 die de neerlegging ter griffie van het verslag en van het dossier gelast;

Gelet op de kennisgeving van het verslag aan partijen en gezien de laatste memories;

Gelet op de beschikking van 16 juli 2007 waarbij de terechtzitting bepaald wordt op 25 september 2007;

Gehoord het verslag van kamervoorzitter D. Verbiest;

Gehoord de opmerkingen van advocaat S. Logie, die loco advocaat D. Van Heuven verschijnt voor de verzoekende partij, en van advocaat L. Schellekens, die verschijnt voor de verwerende partij;

Gehoord het eensluidend advies van auditeur P. Barra;

Gelet op titel VI, hoofdstuk II, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973,

OVERWEEGT WAT VOLGT :

De gegevens van de zaak

1. De NMBS schrijft in juni 2001 een overheidsopdracht uit onder de vorm van een raamovereenkomst voor de levering van burelen, kasten en tafels over een periode van 4 jaar. De gekozen gunningswijze is de onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking. De opdracht wordt beheerst door bestek nr. 77-112-002 van 9 januari 2002.

2. Ingevolge de bekendmaking van de opdracht in het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen en in het Bulletin der Aanbestedingen ontvangt de NMBS 17 aanvragen tot deelneming aan de onderhandelingsprocedure. Alle gegadigden voldoen aan de bekendgemaakte selectiecriteria. De NMBS besluit daarom al deze ondernemingen uit te nodigen een offerte in te dienen voor de levering van burelen, kasten en tafels in 4 loten.

In dit bestek worden onder meer de gunningscriteria bepaald als volgt :

“De NMBS kiest de regelmatige offerte die haar het voordeligst lijkt, rekening houdend met de hierondervermelde gunningscriteria gerangschikt in volgorde van afnemend belang :

B Volledigheid van het aangeboden gamma;

B De prijs;

B Concept (kwaliteit, esthetiek, ergonomie).

(...)

De NMBS houdt zich het recht voor de loten te groeperen”.

3. Acht inschrijvers dienen elf offertes in, die op 4 februari 2002 worden geopend. In april 2002 onderzoekt de eenheid Facility Management van de NMBS per lot de conformiteit van de ingediende offertes en beoordeelt ze deze offertes aan de hand van de drie in het bestek vermelde gunningscriteria. Als eindconclusie van deze evaluatie stelt zij voor dat lot 1, 2 en 4 aan TDS Acior zouden worden gegund en dat inzake lot 3 een offerte van Buro Modern zou worden gekozen.

4. In navolging van de conclusies van de eenheid Facility Management doet de eenheid Aankopen van de NMBS het voorstel - in het Frans - om de loten 1, 2 en 4 aan TDS Acior en lot 3 aan Buro Modern toe te wijzen.

5. Dit voorstel wordt op 16 mei 2002 door het bevoegd orgaan van de NMBS goedgekeurd.

6. Bij aangetekende brief van 24 mei 2002 trekt Buro Modern haar offerte voor lot 3 in. Daarop besluit de NMBS op 27 juni 2002 lot 3 eveneens aan TDS Acior toe te wijzen, op de vier loten een korting van 2% daarbij in rekening brengend.

7. Bij brief van 18 juni 2002 brengt de NMBS in het Nederlands er de verzoekende partij NV Mewaf International van op de hoogte dat haar offertes niet werden gekozen. Hierop verzoekt NV Mewaf International bij brief van 25 juni 2002 de NMBS haar de gemotiveerde beslissing terzake te bezorgen. Bij aangetekende brief van 10 juli 2002 laat de NMBS aan NV Mewaf International weten dat haar “offerte niet de meest interessante was” en deelt zij haar “interne documenten met de gemotiveerde beslissing” mee. Deze documenten zijn vijf

bladzijden uit de evaluatieverslagen waarop de voormelde beslissing steunt. Ze zijn enkel in het Frans geredigeerd.

De ontvankelijkheid

8. De verwerende partij werpt in haar memorie van antwoord in een exceptie op dat het beroep niet ontvankelijk is in zoverre het strekt tot nietigverklaring van de impliciete weigeringsbeslissingen om de loten van de opdracht aan de verzoekende partij toe te kennen.

9. In het auditoraatsverslag wordt de exceptie gegrond bevonden. De verzoekende partij reageerde in haar laatste memorie op dat punt niet op de inhoud van het auditoraatsverslag. Er wordt dan ook aangenomen dat zij niet langer aandringt en dat het beroep niet ontvankelijk moet worden verklaard wat het tweede en vierde voorwerp ervan betreft.

De gegrondheid van het beroep

10. De verzoekende partij voert als eerste middel aan hetgeen volgt :

“A. Eerste middel, betrekking hebbende op de vier bestreden beslissingen : Schending van art. 41 §§ 1 en 2 van de wetten van 18 juli 1966 op het gebruik der talen in bestuurszaken.

1. De publicatie van de overheidsopdracht is geschied zowel in het Nederlands als in het Frans. Ook het bestek was voor de inschrijvers beschikbaar zowel in het Nederlands als in het Frans. In het bestek wordt bepaald dat de inschrijver uit deze twee talen mag kiezen.

Verzoekster heeft een Nederlandstalige offerte ingediend.

Zij werd met Nederlandstalige brief in kennis gesteld dat haar offerte niet werd weerhouden.

Met Nederlandstalige brief heeft zij zich bij verwerende partij bevraagd om een gemotiveerde beslissing.

Bij de Nederlandstalige begeleidende brief van 10 juli 2002 werd, om redenen die voor verzoekster totaal onbegrijpelijk zijn, een in het Frans opgestelde gemotiveerde beslissing overgemaakt.

2. Art. 41 van de taalwet bestuurszaken luidt :

‘§1. De centrale diensten maken voor hun betrekkingen met de particulieren gebruik van die van de drie talen waarvan de betrokkenen zich hebben bediend.

§2. Aan de private bedrijven, die gevestigd zijn in een gemeente zonder speciale regeling uit het Nederlandse of het Franse taalgebied, wordt echter in de taal van dat gebied geantwoord.’

Verweerster diende dus een Nederlandstalige beslissing mee te delen in plaats van een Franstalige.

De nietigheid raakt de openbare orde. Zij dient ambtshalve vastgesteld te worden en is niet afhankelijk van enig geschaad belang.

De Raad van State heeft in het verleden dan ook in gelijkaardige gevallen reeds gunningsbeslissingen vernietigd”.

11. De verwerende partij antwoordt hetgeen volgt :

“12. De NMBS merkt op dat de bijlage aan het nederlandstalig schrijven van 10 juli 2002 een intern document is, zoals dit trouwens in voormeld schrijven uitdrukkelijk werd aangegeven. Overeenkomstig artikelen 39, § 1 en 17, § 1, b, 3/ Taalwet Bestuurszaken gebruiken centrale diensten, zoals de NMBS, voor zaken die niet gelokaliseerd of niet lokaliseerbaar zijn in hun binnendiensten de taal van het toelatingsexamen van de ambtenaar aan wie de zaak werd opgedragen, wat in casu het Frans was.

Artikel 41, § 2 Taalwet Bestuurszaken schrijft weliswaar voor dat aan de private bedrijven, die gevestigd zijn in een gemeente zonder speciale regeling uit het Nederlandse of uit het Franse taalgebied, geantwoord wordt in de taal van dat gebied. De NMBS heeft het schrijven van nv Mewaf International van 25 juni 2002 dan ook beantwoord met een Nederlandstalig schrijven van 10 juli 2002, waarin zij overigens uitdrukkelijk heeft gesteld dat zij ter beschikking bleef voor verdere inlichtingen (zie stuk 17).

Derhalve heeft de NMBS de Taalwet Bestuurszaken gerespecteerd.

13. Indien Uw Raad niettemin van oordeel zou zijn dat de gemotiveerde beslissingen niet zijn genomen in de door de Taalwet Bestuurszaken voorgeschreven taal, dan zal uw Raad dienen vast te stellen dat deze gemotiveerde beslissingen slechts nietig zijn naar vorm [...]. Een nietigheid naar de vorm heeft de nietigheid van de handeling tot gevolg, maar met de mogelijkheid om die nietige handeling te vervangen door een stuk dat wel regelmatig is naar de vorm, waarbij deze vervanging terugwerkende kracht heeft tot op de datum van het oorspronkelijke stuk [...]. Bijgevolg zal de NMBS deze eventueel vast te stellen nietigheid ongedaan kunnen maken door de betreffende gemotiveerde beslissing in het Nederlands op te stellen, waarbij deze Nederlandstalige gemotiveerde beslissingen dezelfde datum zullen dragen als de vervangen gemotiveerde beslissingen. In die omstandigheden is niet goed in te zien welk belang verzoekster bij dit middel kan laten gelden.

14. Overeenkomstig de vaste rechtspraak van uw Raad wordt de wettigheid van de administratieve handeling niet aangetast door gebreken in de kennisgeving [...]. In de mate dat uw Raad zou oordelen dat de kennisgeving van de gemotiveerde beslissingen niet in de door de Taalwet voorgeschreven taal zou zijn gebeurd, dan zal deze onregelmatigheid in de kennisgeving geen aanleiding kunnen zijn tot de vernietiging van de gunningsbeslissingen.

Besluit : In de mate dat het eerste middel gericht is tegen de gemotiveerde gunningsbeslissingen, moet dit middel als ongegrond worden verworpen. Voorzover het eerste middel evenwel zou opwerpen dat de kennisgeving als dusdanig artikel 41, §§ 1 en 2 van de gecoördineerde wetten van 18 juli 1966 op het gebruik van de talen in bestuurszaken schendt, is dit middel onontvankelijk”.

12. Bij het middel werpt de verwerende partij in de eerste plaats op dat niet goed is in te zien welk belang de verzoekende partij bij het middel kan laten

gelden, nu de bestreden beslissing bij een eventuele nietigverklaring zou kunnen worden vervangen door een regelmatig stuk met terugwerkende kracht.

Terzake wordt vastgesteld dat de verzoekende partij zich beroept op een middel dat steunt op de schending van een wet die beoogt de openbare orde te beschermen. Dit middel zou in beginsel zelfs ambtshalve moeten worden aangevoerd. De exceptie van niet-ontvankelijkheid van het middel kan in die omstandigheden niet worden ingewilligd.

13. Niet betwist wordt dat de te dezen opgetreden diensten van de verwerende partij “centrale diensten” zijn in de zin van het in het middel aangehaalde artikel 41,§1 van de op 18 juli 1966 gecoördineerde wetten op het gebruik van talen in bestuurszaken. De verzoekende partij heeft haar zetel in een gemeente zonder speciale regeling in het Nederlandse taalgebied. Overeenkomstig artikel 41,§2, moet haar dan worden geantwoord “in de taal van dat gebied” waar ze is gevestigd.

De verwerende partij gaat er van uit dat de gemotiveerde toewijzingsbeslissing een “intern document” is, volgens haar laatste memorie “uitsluitend gericht [...] aan [haar] binnendiensten met het oog op de beoordeling van de ingediende offertes”.

In die stelling wordt zij niet bijgevalen. Een centrale dienst die een gemotiveerde toewijzingsbeslissing meedeelt aan een inschrijver treedt immers in betrekking met die particulier. De gemotiveerde beslissing is daarbij niet als een intern document te beschouwen nu, gelet op de toepasselijke bepaling vervat in artikel 51,§2, van het koninklijk besluit van 8 januari 1996 betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en de concessies voor openbare werken, het van in den beginne vaststond dat de bedoelde beslissing diende te worden gemotiveerd en die motivering aan de inschrijver moest worden medegedeeld op zijn verzoek, nu zijn offerte niet was gekozen. Dienvolgens mogen de beslissing en haar motieven niet van elkaar worden onderscheiden teneinde deze te onderwerpen aan een verschillend taalregime. De bestreden beslissing die in haar geheel te beschouwen is als “antwoord” op de offerte ingediend door de verzoekende partij, diende aldus te haren opzichte in de vorm van een beslissing in het Nederlands te zijn gesteld en aldus aan de verzoekende partij ter kennis te worden gebracht, teneinde te voldoen aan het voorschrift van het

voormelde artikel 41,§2, krachtens hetwelk diende te worden geantwoord in de taal van het gebied waarin de private onderneming is gevestigd, te dezen het Nederlandse taalgebied.

Het middel is gegrond.

**OM DIE REDENEN
BESLIST DE RAAD VAN STATE :**

Artikel 1.

Vernietigd wordt de beslissing van de NMBS vervat in haar stuk 13 houdende de toewijzing in het kader van een overheidsopdracht volgens bestek nr 77-112-002 betreffende de aankoop van kantoormeubilair van loten 1, 2, 3 en 4 aan TDS Acior voor een totaal bedrag van 1.916.993,68 euro.

Artikel 2.

Het beroep wordt voor het overige verworpen.

Artikel 3.

De kosten van het beroep tot nietigverklaring, bepaald op 175 euro, komen ten laste van de verwerende partij.

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting, op achtentwintig februari 2008, door de XIIe kamer, die was samengesteld uit :

de HH.	D. VERBIEST,	kamervoorzitter,
	J. LUST,	staatsraad,
	G. VAN HAEGENDOREN,	staatsraad,
Mevr.	S. DOMS,	griffier.

De griffier,

De voorzitter,

S. DOMS.

D. VERBIEST.